

1500628-51.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas, com incidência de uma causa de aumento relativa ao tráfico entre Estados da Federação (art. 33, caput, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/06), e de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, caput, Lei nº. 11.343/06), em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal).

A ação penal é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500628-51.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500628-51.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2104749/2020 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 11157521 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI,

1458/2020 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2104749 - 02º D.P. BIRIGUI, 1458/20/309 - 02º

D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIA REGINA ALVES FROIS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500628-51.2020.8.26.0603 (Controle nº 692/20).

VISTOS.

EVAIR DOS SANTOS e SILVIA REGINA ALVES FROIS, qualificados nos autos, foram presos em flagrante delito, denunciados e viram-se processados como

incurso no artigo 33, caput, e 35, caput, c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 28 de abril de 2020, por volta das 17h34min, à Avenida Nove de Julho, via pública, altura do numeral 2.875, Novo Jardim Stábile, nesta cidade e Comarca de Birigui, transportavam 20,77 kg (vinte quilogramas e setenta e sete decagramas) de maconha distribuídos em 17 (dezessete) porções, substância entorpecente, que determina dependência física psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação prévia de fls. 31 e exame toxicológico de fls. 158/160.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, EVAIR DOS SANTOS e SILVIA REGINA ALVES FROIS, qualificados nos autos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados para apresentarem defesas escritas (fls. 197 e 199), cujas peças foram juntadas às fls. 162/164 e 166/177, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 26 de outubro de 2020 (fls. 207/208).

Na instrução, foi colhido o depoimento de 01 (uma) testemunha arrolada em comum (fls. 269/270), sobrevivendo, ao final, os interrogatórios dos acusados (fls. 314/315).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, com a condenação do réu Evair e a absolvição da ré Silvia (fls. 321/328).

A defesa da ré Silvia pediu a improcedência da ação, alegando insuficiência de provas, vez que não restou comprovada a prática de conduta criminosa pela ré.

Pleiteou a restituição do veículo apreendido (fls. 331/335).

Por fim, a defesa do réu Evair sustentou que ele praticou o crime porque é usuário. Requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como o reconhecimento da confissão. Pleiteou, também, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a possibilidade de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06 (fls. 351/364).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas, com incidência de uma causa de aumento relativa ao tráfico entre Estados da Federação (art. 33, caput, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/06), e de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, caput, Lei nº. 11.343/06), em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal).

A ação penal é parcialmente procedente.

Considerando que a presente ação penal apura a prática de duas infrações, passo a analisar separadamente os crimes, para melhor elucidação dos fatos.

Tráfico de drogas.

No tocante ao crime de tráfico imputado aos réus, ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia (para ambos os acusados) ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Neste sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; o auto de exibição e apreensão encartado à fl. 14; o boletim de ocorrência acostado às fls. 10/13; as notas de culpa de fls. 08/09; o laudo de constatação prévia de fl. 31; os autos de depósitos de fls. 15 e 179; o laudo pericial de fls. 158/160; o relatório policial de fls. 103/108; o depoimento da testemunha; a confissão do réu Evair e a indigesta negativa da ré Silvia apresentada na fase judicial.

Na fase extrajudicial, os acusados preferiram exercer o direito de permanecerem em silêncio (fls. 05 e 06/07), desperdiçando importante oportunidade para apresentarem uma versão convincente dos fatos. Aliás, o fato de os réus terem ficado em silêncio, embora não se deva tomar por prova plena e cabal de suas culpas, induz à invencível perplexidade quanto à sua inocência, pois repugna a razão deixe alguém

de responder aos termos de uma acusação, máxime se inocente. Com o silêncio, pois, os réus tiveram atitude incompatível com quem se diz inocente, perdendo a oportunidade de esclarecerem equívoco da acusação. Lembre-se que o silêncio dos acusados não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz, nos termos do artigo 198 do Código de Processo Penal.

O acusado Evair, em juízo, confessou os fatos imputados na denúncia, disse que transportou a droga da cidade de Três Lagoas/MS para um indivíduo chamado Marcelo e receberia um tablete de maconha como pagamento. Disse que Sílvia nada sabia, pois mentiu para ela, pedindo que o levasse até a cidade para ver um serviço e que ela soube da droga somente no momento da abordagem (fls. 314/315). Como se vê, o réu Evair confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, porém, tentou isentar a acusada Sílvia de sua responsabilidade penal. A confissão livre e espontânea prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos. De fato, no caso, a confissão do réu Evair, quanto ao transporte da droga, encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos. Contudo, a versão do acusado, ao tentar afastar a responsabilidade da corré, está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, como se verá logo abaixo.

Já a acusada Sílvia, na fase judicial, negou a prática criminosa. Disse que mantinha um relacionamento com Evair e que pegou emprestado o carro do seu ex-marido para levar e acompanhar Evair em um serviço que ele tinha arranjado. Na cidade, Evair desceu com uma bolsa de roupas e voltou depois guardando a bolsa no carro, informando que não havia conseguido o emprego. Retornaram por uma estrada de terra e Evair somente lhe contou sobre a droga momentos antes da abordagem. Confirmou que disse aos policiais que sabia da droga (fls. 314/315). A negativa apresentada pela ré não merece credibilidade, pois está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isoladas de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariadas por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada. Com efeito, a testemunha Matheus Henrique Bertoldo Martins, policial militar, ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava em patrulhamento quando passou pelo posto de combustível que fica às margens da rodovia SP 300, quando viu que o veículo VW/Fox que seguia pela referida rodovia deu sinal para adentrar no posto, contudo, voltou para a estrada, ao ver a viatura policial. Acompanhou o automóvel e, ao abordar e revistar o carro, encontrou uma bolsa no assoalho atrás do banco do motorista, com tijolos de maconha. O réu Evair confessou que buscou a droga na cidade de Três Lagoas/MS para uma pessoa chamada Marcelo e ganharia alguns tijolos como pagamento. A acusada Sílvia estava no banco de passageiro e tinha ciência que Evair teria ido buscar a droga e confirmou que o carro era de sua propriedade (fls. 04 e 267/270).

No mesmo sentido, o depoimento do policial Josias Guerrero Junior, ouvido apenas na delegacia (fl. 03).

Os relatos dos policiais não deixam dúvidas de que os réus incidiram na prática de tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que confirmaram a apreensão dos entorpecentes no veículo da ré Sílvia, que era conduzido pelo réu Evair. Confirmaram ainda que a ré Sílvia afirmou e sabia da prática criminosa realizada pelo acusado.

Evidente, pois, a participação da corré Sílvia no tráfico de drogas.

O valor dos depoimentos policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor

na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar os acusados, ou em imputar falsamente a eles a prática de condutas definidas como crime, sobretudo porque não se apontou nada que justificasse essa circunstância.

A substância apreendida consiste realmente em maconha (fls. 158/160).

De outra parte, a quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 quilos de maconha, conforme se constata do citado laudo); as circunstâncias da abordagem dos réus (condutor, ao avistar os policiais, alterou a trajetória), a forma de acondicionamento da droga (embalada em porções), a apreensão de dinheiro e celular, bem como a confissão do acusado Evair, estão a caracterizar a traficância.

Quanto ao dinheiro apreendido, os acusados não comprovaram suas origens, providências essas que seriam de fácil consecução, arrolando testemunhas ou juntado documentos para confirmar a licitude do capital.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente transporte droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Lembre-se que os réus foram denunciados por transportarem as drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Portanto, a prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria do crime por parte dos réus, no crime ora apurado. Lembre-se que, no caso, não se exige o chamado "dolo específico", mas apenas o dolo genérico, restando evidente que transportavam a droga descrita na denúncia para entrega a consumo de terceiros.

Por fim, a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, também restou demonstrada, quer pela confissão do réu Evair, quer pelos depoimentos dos policiais, que confirmaram que os réus estavam vindo do Estado de Mato Grosso do Sul e foram abordados no Estado de São Paulo, inclusive, os próprios réus afirmaram que a droga saiu de Três Lagoas/MS e estava sendo transportada para Birigui/SP, onde seria entregue para a pessoa chamada "Marcelo".

Portanto, referida causa de aumento é aplicada quando restar comprovado que os réus praticaram qualquer uma das condutas descritas no caput do artigo 33, também nas situações trazidos pelo artigo 40 da Lei de Drogas, o que foi o caso dos autos. É óbvio que alguém que transporte vinte quilos de cocaína, tinha a intenção de "pulverizá-la" ou "disseminá-la" em outro Estado. E ainda que a intenção dos réus fossem apenas transportar, e não pulverizar ou disseminar a droga, a conduta dos réus está tipificada no artigo 33, caput, e 40, inciso V, da Lei de Drogas, lembrando que o artigo 33 é chamado de misto alternativo, razão pela qual, praticado qualquer um dos verbos nele tipificados, haverá a configuração do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, os acusados transportavam 20,77 quilogramas de maconha, sendo que o faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora a defesa do réu Evair tenha alegado que o acusado é usuário de droga, tal alegação não restou comprovada, até porque a defesa não juntou qualquer documento, não requereu qualquer exame de

dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental. Ademais, o réu demonstrou-se lúcido em seu interrogatório.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de droga, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra conduta. Se o réu era viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas. Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Por consequência, fica rejeitada a pretensão da defesa de Evair, de desclassificação do crime imputado para o de uso de substância tóxica previsto no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito.

Associação para o tráfico.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, a ação é improcedente em relação aos dois réus, porque não há provas suficientes de que os acusados estariam associados para o fim de praticarem crimes de tráfico ilícito de drogas, como constou da denúncia.

De início, é necessário esclarecer que o artigo 35, caput, da Lei nº. 11.343/06, dispõe ser crime a associação para praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei. Logo, não há como condenar alguém nas severas penas do artigo 35, caput, da Lei nº. 11.343/06, quando não provados cabalmente a estabilidade, a permanência e o liame associativo entre os réus. Outros elementos de prova deveriam ser oferecidos para que fosse admissível a pleiteada condenação criminal contra os réus neste delito, que não admite dúvidas e não pode ser lastreada apenas em indícios, como neste caso: pode até haver indícios fortes de que os réus se associaram para praticarem, de forma estável e permanente, o tráfico de drogas, mas não se produziu prova plena neste sentido, havendo dúvida insuperável, motivo pelo qual a solução que se impõe é a absolvição desses acusados, por falta de provas, quanto à associação.

Por outro lado, embora comprovado o concurso eventual de agentes, a lei de droga atual deu abrigo aos termos do antigo art. 14 da Lei 6.368/76 (atual art. 35), mas não fez o mesmo com a figura da "associação eventual" (antigo art. 18, III), não tendo sido retratada ou tipificada na nova legislação, razão pela qual entendo que não pode mais prevalecer qualquer penalização por conta da figura da associação eventual, que não foi recepcionada pela atual legislação que combate a disseminação das drogas em nossa sociedade.

Em função disto, e não havendo provas, pelos elementos acima analisados, da associação permanente e estável entre os réus para o tráfico de drogas, entendo que a autoria não está devidamente comprovada com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, Editora RT, 8ª edição, página 689, nota 44 ao artigo 386, se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

Importa referir que o sistema penal se assenta na presunção de inocência dos réus. Assim sendo, para condenação dos réus, a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição, basta a dúvida, consagrando o princípio "in dubio pro reo", contido no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo, doravante, à aplicação da pena em relação ao tráfico de drogas.

Réu Evair.

O acusado ostenta péssimos antecedentes (fls. 366/369 – Processos nºs 0014974-54.2001.8.26.0019, 0014175-26.2002.8.26.0132 e 0001437-58.2010.8.26.0218), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe são favoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Afora isso, nesta fase

da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução, no mercado, da considerável quantidade de droga apreendida se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-los com a sanção base mínima, tratando-os igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repressão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154).

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277).

Portanto, levando em conta o dado elencado, nos aspectos acima relatados (péssimos antecedentes e quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois confessar, no âmbito do processo penal, é admitir, contra si, a prática de algum fato criminoso. O réu assim procedeu em seu interrogatório (embora tenha tentado afastar a responsabilidade da ré Silvia), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Não há agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, é de se reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 40,

inciso V, da Lei nº. 11.343/06, porquanto a prova oral é segura o bastante para afirmar que a prática delitiva ocorreu entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, como destinatário final da droga. Logo, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 809 (oitocentos e nove) dias-multa.

Ainda nesta fase, não incide, no caso, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, primeiramente, porque o acusado ostenta maus antecedentes, o que impede o reconhecimento dessa causa de diminuição de pena. Além disso, restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de drogas (20,77 quilogramas), que o acusado se dedicava à narcotraficância em escala expressiva, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida. Neste sentido, já se decidiu:

“ Sem incidência , porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida – para fim de venda a indeterminado número de pessoas – antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa.”

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz jus à redução em questão.

Torno, pois, definitivas as penas em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 809 (oitocentos e nove) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ré Silvia

A acusada é primária e não registra mau antecedente, além do que as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis para efeito de fixação das penas.

Porém, pelos mesmos motivos expostos quanto ao réu Evair, no tocante à quantidade da droga apreendida, elevo a pena-base em 1/2 (metade), resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, é de se reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06, porquanto a prova oral é segura o bastante para afirmar que a prática delitiva ocorreu entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, como destinatário final da droga. Logo, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

De igual modo, pelos mesmos motivos expostos quanto ao réu Evair, no tocante à quantidade da droga apreendida, entendo não ser o caso da incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Torno, pois, definitiva a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), as penas privativas de liberdade devem ser cumpridas no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois o crime de tráfico é equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do

regime prisional, na hipótese, com análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos acusados, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta adequação que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

Como se verá doravante, estão presentes os requisitos da custódia cautelar, devendo os acusados continuarem a responder presos por este processo, como o fizeram durante toda a instrução.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- 1-) ABSOLVER EVAIR DOS SANTOS e SILVIA REGINA ALVES FROIS, qualificados nos autos, da imputação constante da denúncia no tocante ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
 - 2-) CONDENAR SILVIA REGINA ALVES FROIS, qualificada nos autos, ao cumprimento das penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07) e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-a como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, nos moldes do artigo 29, do Código Penal;
 - 3-) CONDENAR EVAIR DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07) e pagamento de 809 (oitocentos e nove) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, nos moldes do artigo 29, do Código Penal.
- Consigno que os acusados estão presos cautelarmente desde 28/04/2020 até a presente data, períodos sobre os quais fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restando da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Recentemente, foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima. Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, recente decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS – mencionado nas razões recursais –, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente – até as pedras estão cansadas de saber –, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que – até o momento – jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido recentemente em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade.

Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão

somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem tais argumentos, anoto que as penas aplicadas aos réus superaram quatro anos e eles foram pegos com grande quantidade de droga, o que afasta também a substituição da pena privativa de liberdade, que não seria suficiente para a prevenção e repressão do crime. Ademais, o réu Evair ostenta péssimos antecedentes criminais, o que também torna inviável a mencionada substituição.

Os acusados deverão continuar a responder presos a este processo, eis que foram decretadas suas prisões preventivas, conforme decisão proferida às fls. 67/68, a cujos argumentos me reporto, como razão de decidir, assim como aqueles expostos às fls. 22/23, do apenso 0002703-66.2020.8.26.0077, que indeferiu pedido de liberdade provisória formulada pela ré Silvia.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar dos acusados, mormente porque praticaram delito equiparado aos hediondos.

A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos acusados, estão as decisões proferidas no Habeas Corpus impetrado em favor da acusada Silvia, que teve sua liminar indeferida, e, ao final, a ordem denegada (fls. 151 e 370/374).

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada (fls. 67/68) e realizada (fl. 286), nada havendo a ser decidido.

Como os acusados não fizeram prova da procedência lícita do dinheiro e dos celulares apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 14, não há como se deixar de reconhecer que são produtos e instrumentos do tráfico de entorpecentes por eles praticados, assim como o veículo utilizado na prática do transporte da droga.

Logo, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos celulares e do dinheiro apreendidos à fl. 14, bem como do veículo depositado à fl. 15, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento, instruindo-se o ofício com as cópias mencionadas no parágrafo anterior.

Por fim, com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral,

nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas na forma da Lei.

P. R. I.

Birigui, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA